

1501551-13.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... Em juízo, confessou o tráfico, alegando que praticou o crime para sustentar o seu vício, porque é dependente de "crack". Está arrependido e pede uma oportunidade para voltar a estudar e trabalhar. Tem 20 anos. Possui condenação por tráfico. Trabalhava com seu pai como ambulante.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/03), disseram que foram até o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1501551-13.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501551-13.2022.8.26.0537 Controle nº 1147/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVI BENATTI CHAVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

DAVI BENATTI CHAVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 23 de julho de 2022, por volta das 11:54 horas, na Rua Bethoven, n.º 10, Bairro Casa Grande, trazia consigo e guardava, para consumo de terceiros, cocaína e maconha, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 42/44).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 84/85), sendo recebida a denúncia em 30.09.22 (fls. 88/89). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.ª Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de drogas e pela agravante da reincidência específica, que seja afastada a aplicação do art. 33, § 4.º por ser reincidente e fixação de regime fechado.

O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de eventual condenação, a compensação da reincidência com a menoridade e confissão judicial, a fixação de regime semiaberto diante da detração penal.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial, o acusado negou a prática do crime (fls. 06).

Em juízo, confessou o tráfico, alegando que praticou o crime para sustentar o seu vício, porque é dependente de "crack". Está arrependido e pede uma oportunidade para voltar a estudar e trabalhar. Tem 20 anos. Possui condenação por tráfico. Trabalhava com seu pai como ambulante.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/03), disseram que foram até o local dos fatos em razão de uma denúncia anônima, encaminhada via COPOM, que relatava a prática de tráfico de drogas por um homem que escondia uma mochila de cor azul em um pneu. Narraram que no local se depararam com o réu, que possuía as mesmas características informadas na denúncia anônima e perto dele acharam a mochila de cor azul. Relataram que em vistoria na mochila localizaram uma calculadora, a quantia de R\$ 90,00, 44 pedras de "crack", 23 invólucros de cocaína e 56 porções de maconha. Falaram que o réu resistiu à abordagem, razão pela qual tiveram que usar de força moderada para prendê-lo e algemá-lo. Informaram que o réu apresentava escoriações do lado direito do rosto, por isso o encaminharam ao Hospital Municipal de Diadema para atendimento médico e, posteriormente, ao distrito policial.

Rafael (policial), em juízo, afirmou que o COPOM dava as características do homem que traficava e onde colocava as drogas (atrás do pneu com vaso de plantas). O réu tinha as mesmas características, estava próximo do pneu, o abordaram e em seu poder havia dinheiro e uma porção de "crack" e na mochila perto dele tinha mais drogas. Não havia pessoas próximas do acusado. O réu ficou calado. As drogas estavam divididas em porções. Não conhecia o réu anteriormente.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Marcos. Acrescentou que as drogas estavam escondidas em uma bolsa em um pneu na praça. Narrou que foi ele que diligenciou e encontrou nos pneus uma mochila com drogas, divididas em porções, semelhantes à que o réu tinha no bolso. O réu negou, alegando que é usuário e que não sabia da bolsa. A bolsa estava há uns dois metros do réu. Informou que o réu estava machucado e o levaram para o hospital e depois para a delegacia. Não conhecia o réu anteriormente. Esclareceu que não viram o réu mexendo na bolsa, mas o mesmo estava sentado num banco ao lado, há uma distância de uns 2 ou 3 metros da bolsa que continha drogas. Informou que apenas o réu estava próximo dessa bolsa.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º

1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

O réu nada disse contra os policiais, pelo que não teriam motivos para incriminá-lo indevidamente.

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 19 - 44 pedras de "crack", 23 invólucros de cocaína e 56 porções de maconha), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em invólucros, que foi apreendido dinheiro, não sendo demonstrada sua procedência, a confissão judicial, bem como os depoimentos dos policiais, demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade e variedade se não fosse traficante.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciado pelas condutas de adquirir e trazer consigo.

A confissão judicial foi corroborada pelos depoimentos dos policiais e pela denúncia anônima, pois suas características coincidiam com as informadas, as drogas foram apreendidas no local apontado e apenas o réu estava próximo das mesmas (sentado na praça há uma distância de uns dois ou três metros do pneu onde estava

escondidas as drogas dentro de uma bolsa), pelo que irrelevante que os policiais não o viram mexendo na bolsa ou pneu.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Desta forma, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 27/29) e laudo definitivo (fls. 103/105).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é reincidente (fls. 34/35 - proc. 1501512-50.2021). O processo em andamento não pode ser considerado como antecedente em face do princípio do estado de inocência (fls. 35 - proc. 1501516-24.2020).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o tráfico, em razão da quantidade média de drogas (fls. 19 - 44 pedras de "crack", 23 invólucros de cocaína e 56 porções de maconha), já que pequena quantidade nesta Comarca é inferior a 100 invólucros e enorme de quilos, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado.

Compenso a reincidência com a menoridade do acusado e confissão judicial, porque ambas são preponderantes, pelo que a pena permanece inalterada.

Nesse sentido:

"A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.^a Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: "ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.^a ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito recente decisão do STJ:

Processo

AgRg no Resp 1406723 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2013/0328868-9

Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESP N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do ERESP n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do

Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

O réu não faz jus à redução do art. 33, §4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário) que são cumulativos, além de se dedicar a atividades criminosas, já que ostenta condenação anterior também por tráfico.

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, § 2.º, “b” e “c” só se aplicam regimes mais brandos ao “condenado não reincidente”. As circunstâncias não são favoráveis, pois é reincidente específico (fls. 34/35 – proc. 1501512-50.2021), o que denota personalidade voltada para crimes, uma vez que sequer provou possuir ocupação lícita, o que demonstra que o tráfico é seu meio de vida e, ainda, houve aumento da pena pela quantidade de drogas. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou “sursis”, diante do montante da pena.

Inaplicável o disposto no art. 387, §2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, “Lex specialis derogat generali” (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em 23.07.22, pelo que ainda que considerado 2/5 só ocorreria em 22.11.24).

Por outro lado, “ad argumentandum”, ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência específica (circunstância judicial agravante), não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO DAVI BENATTI CHAVES à pena de 5 (CINCO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO e 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06.

Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei n.º 8072/90, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou ocupação lícita nem residência fixa) e é incabível qualquer benefício, recomenda-se na prisão em que se encontra.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 19 e 106 – R\$ 90,00), conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Em relação à mochila marca "Maxsteel" e à calculadora eletrônica portátil com inscrição "Danielle", apreendidas (fls. 19) e já periciada (fls. 102), tendo em vista que não possuem valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessam mais aos autos podendo ser eliminadas.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 48) e providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06) e efetue-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 20 de outubro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA